

1500399-03.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... "olheiro" e "vigia", ao executor do tráfico de drogas, o adolescente Gustavo Emanuel Alves Francisco, que trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 19 pedras de crack, pesando cerca de 4g; e 722 supositórios contendo cocaína, com aproximadamente 1.030g, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudos de exames ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-03.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-03.2022.8.26.0545 Controle nº 531/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2097814/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA

PLANTÃO, 24195160 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2097814 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 40/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIAN WESLEY DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

RIAN WESLEY DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, da Lei 11.343/06

c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, na tarde de 08 de abril de 2022, sexta-feira, por volta das 15h15min, na Rua Júlio Bonucci Filho, nº. 73, Jardim Morumbi, neste Município e Comarca de Bragança Paulista, prestou auxílio moral e material, na função de "olheiro" e "vigia", ao executor do tráfico de drogas, o adolescente Gustavo Emanuel Alves Francisco, que trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 19 pedras de crack, pesando cerca de 4g; e 722 supositórios contendo cocaína, com aproximadamente 1.030g, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudos de exames químico-toxicológicos juntados, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 89) e apresentou defesa preliminar (fls. 108/109). A denúncia foi recebida em 09.05.2022 (fls. 111/113), e o réu foi devidamente citado (fls. 131).

Durante a instrução, foi produzida a prova oral, através de audiência por videoconferência, com a oitiva de duas testemunhas comuns, bem como com o interrogatório do réu (fls. 132/133).

Encerrada a instrução, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos, ocasião em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, tecendo, ainda, considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 152/159).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, em razão da fragilidade do conjunto probatório, em demonstrar a ocorrência do tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/06, com base no princípio da proporcionalidade. Pleiteou, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo. Pugnou, por fim, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão da execução da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade (fls. 163/178).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal procede.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo auto de constatação preliminar (fls. 22/23), pelos laudos periciais das drogas (fls. 95/99), assim como pelos depoimentos colhidos.

A autoria delitiva também é certa.

Extrajudicialmente, o acusado alegou que, na data em questão, foi abordado em frente à residência de seu amigo Gustavo, ocasião em que nada de ilícito fora localizado consigo. Tinha ciência de que o amigo vendia drogas no local, explicando que, na ocasião, prestava-lhe auxílio em tal atividade, vigiando o entorno, a fim de avisá-lo caso a polícia aparecesse. Receberia de Gustavo, ao final do dia, quantia em dinheiro relativa a tal serviço prestado. Afirmou, por fim, desconhecer que Gustavo armazenava as drogas que a polícia localizou no telhado da residência (fls. 13/14).

Igualmente, quando ouvido em juízo, o acusado afirmou que, na data em questão, encontrava-se na via pública, conversando com vizinhos, quando Gustavo, menor de idade, que conhecia de vista há duas semanas, se aproximou e passou a conversar consigo. Em dado momento, ele lhe solicitou que vigiasse o local para que ele pudesse vender os entorpecentes que levava. Concordeu em atuar dessa maneira, pois o menor lhe recompensaria com dinheiro, o qual utilizaria para comprar drogas. Logo em seguida, surgiram os policiais, ocasião em que, prontamente, avisou sobre a chegada deles ao menor, que esboçou reação de fuga, mas acabou por permanecer no local. Os agentes efetuaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram os entorpecentes em posse de Gustavo, bem como aqueles que ele mantinha em sua residência.

O conjunto probatório existente nos autos, por sua vez, corrobora a confissão prestada e demonstra que o acusado incorreu no delito que lhe é imputado na peça acusatória.

A testemunha comum, guarda municipal Marcos Aurélio Picarelli, explicou que se encontrava em patrulhamento quando avistou, na via pública, o acusado e outro indivíduo, que lhe eram desconhecidos e ameaçaram empreender fuga ao visualizarem a viatura. Abordados e revistados, com o menor foi localizada certa quantia de drogas em seu bolso, ao passo que, com o acusado, nada de ilícito foi encontrado.

Indagado, o réu afirmou que se encontrava no local pois era usuário de entorpecentes. Contudo, o outro indivíduo, que se encontrava com ele, disse que o acusado era um olheiro do tráfico, e o auxiliava na venda de drogas. Recordou-se, ainda, de ter se dirigido até à residência do indivíduo menor de idade, onde mais droga fora localizada. Pontuou, todavia, não ter diligenciado a residência do acusado, uma vez que ele informou que lá não armazenava entorpecentes.

No mesmo sentido, a testemunha comum, guarda municipal Rodrigo Durães Carlini, narrou que efetuava patrulhamento em um conhecido local de tráfico de drogas da cidade, quando visualizou dois jovens, que lhe eram desconhecidos, em atitude suspeita. Descreveu ter notado um certo volume no bolso do adolescente, o qual, ao notar a equipe, esboçou reação de fuga. Em razão disso, efetuaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram entorpecentes no bolso do indivíduo menor de idade, além de dinheiro e celular. Já com o acusado, nada de ilícito foi localizado, tendo ele afirmado que ali se encontrava por ser usuário de drogas. O menor de idade, contudo, confessou a traficância e informou que o réu atuava como olheiro no comércio de drogas. Em diligência à residência do menor, que se situava em frente ao local dos fatos, e com autorização de sua genitora, foram localizados mais entorpecentes no telhado do imóvel.

Pois bem. Consoante se extrai do conjunto probatório, há prova segura acerca da responsabilidade criminal do acusado.

Observo que os guardas municipais ouviram um relato idêntico àquele exposto por eles em sede policial (fls. 08 /11), esclarecendo, com detalhes, a forma como os fatos se deram.

Ambos informaram terem abordado o réu, juntamente com um indivíduo menor de idade, em razão da atitude suspeita apresentada pelo menor, ocasião em que este lhes confidenciou o tráfico de drogas, informando que o acusado o auxiliava em tal prática, atuando como "olheiro".

As testemunhas ainda descreveram terem localizado crack e cocaína não apenas no bolso do menor, durante revista pessoal, como, também, no telhado de sua residência, situada em frente ao local dos fatos, para onde se dirigiram após sua confissão de que lá armazenava mais entorpecentes.

Anoto que as testemunhas, em razão da função pública que exercem, bem como do compromisso que prestam em juízo de dizer a verdade, merecem total confiabilidade. Mesmo porque, ambas sequer conheciam o acusado e este, por sua vez, nada alegou contra o proceder daquelas.

Da mesma forma, não há indícios mínimos nos autos de algum interesse dos agentes em incriminar, de forma injusta, o acusado, não havendo motivos para deles duvidar ou para excluir seus depoimentos.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência: "Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes".

Ademais, o depoimento dos agentes da lei se coaduna às demais provas coligidas aos autos, especialmente pela apreensão das drogas, que foi consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão, e pelo laudo químico-toxicológico, que confirmou se tratar de cocaína o entorpecente apreendido (fls. 95/99).

E em consonância ao conjunto probatório amealhado aos autos, tem-se, ainda, a confissão de Gustavo, o qual, conforme consta na mídia acostada aos autos a fls. 143, admitiu que praticava o tráfico de drogas na ocasião em questão, ao ser ouvido no feito que correu perante o Juízo da Infância local, onde, inclusive, sua representação foi julgada procedente, sendo a ele imposta medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado (fls. 144/148).

Mais a mais, verifico que o próprio acusado confessou a prática delitiva, nas duas

oportunidades em que ouvido, explicando que, quando dos fatos, atuava como vigia, para que o menor Gustavo praticasse a traficância, pelo que receberia quantia em dinheiro.

E sua confissão não pode ser desprezada, pois se encontra em harmonia com os demais elementos carregados aos autos, sendo, assim, de grande valia para o conjunto probatório.

"A confissão livre, espontânea e não posta em duvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabrini Mirabete, 7ª ed. Ed Atlas S/A-SP.2000, pag 409).

"A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para tipificar a condenação" (RJDTCRIM 40/221). Evidente, pois, o concurso de agentes entre o acusado e o adolescente, os quais se encontravam conluiados para a prática do tráfico, pelo menos naquela data, inclusive com divisão de funções, na medida em que o réu vigiava a ação criminosa, a fim de garantir o seu sucesso, enquanto Gustavo efetivamente atuava no comércio das drogas.

E aqui, necessário salientar que a função de "olheiro" encontra-se diretamente ligada ao tráfico de drogas, caracterizando a coautoria, razão pela qual deve ser afastada a arguição da Defesa, no sentido de readequar a conduta acusado para o tipo penal de mera colaboração, conforme dispõe o artigo 37 da Lei de Tóxicos. Referido tipo penal tem sua razão de ser apenas quando a colaboração se dá, exclusivamente, mediante informação. Qualquer outra forma de colaboração tipifica o delito ora em análise.

Ora, restou devidamente demonstrado que o acusado atuava na mercancia de forma intencional e consciente para promover a venda de drogas, de sorte que não se trata de mero colaborador ou informante.

Nesse sentido: "Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado pelo concurso com adolescente. Sentença condenatória. Recurso da defesa. (...) 2. Não é o caso de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/06. O informante a que alude o tipo penal corresponde ao agente que pratica uma ação acessória no grupo ou organização criminal. No caso, a atividade de "olheiro" assim como a de "segurança", tal como desenhada nos autos, é fundamental ao exercício do comércio de drogas, pois dela depende o sucesso da empreitada criminosa. 3. (...) Negado provimento ao recurso". (TJ-SP -Apelação Criminal nº 1500121-31.2019.8.26.0537, Relator (a): Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 08/10/2019).

"Desclassificação para a conduta do art. 37 da Lei de Drogas. Inocorrência. Alegado pelo réu a função de "olheiro", de qualquer maneira deve ser condenado pelo tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), já que tal atividade, de "olheiro", é diretamente ligada ao hediondo comércio, atuando a pessoa nesse sentido como coautor do delito de tráfico de drogas, porque participando da efetiva execução dele, não se confundindo com a conduta prevista no artigo 37 da Lei 11.343/06, de mero prestador de informações. Negado provimento ao apelo do réu e dado provimento ao reclamo ministerial." (TJ-SP -Apelação Criminal nº 1500583-86.2018.8.26.0548, Relator (a): Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 21/08/2020).

Resta, assim, imputar ao acusado a responsabilidade pelas drogas apreendidas nos autos, as quais eram destinadas à mercancia, praticada em concurso de agentes com o menor Gustavo, conforme restou demonstrado.

E aqui, ressalto que, além da razoável quantia de drogas localizada, os entorpecentes apresentavam naturezas diversas (cocaína e crack), a denotar que a dupla visava atender aos diversos públicos deste mercado ilícito. Ademais, os entorpecentes se encontravam fracionados e embalados individualmente, prontos para a comercialização.

Somado a isso, tem-se, também, a considerável quantia em dinheiro, apreendida em poder de Gustavo, cuja atitude suspeita, inclusive, motivou a abordagem.

Ademais, de se ressaltar que o crime de tráfico de entorpecentes é de múltipla ação, de modo que a incidência em apenas um dos seus verbo-núcleos já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de modo que não se faz necessária a comprovação de mercancia no momento do flagrante policial.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma, por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

Consigno, por fim, que a condição de usuário, alegada pelo réu, a qual o teria levado a atuar como olheiro para Gustavo, não afasta sua responsabilidade diante da conduta praticada.

Vale dizer, não se ignora tratar-se, possivelmente, de um dependente químico, porém tal condição não afasta a condenação pelo tráfico. Mesmo porque, é sabido que muitos usuários incorrem no tráfico como forma de sustentar o próprio vício, e tal circunstância não os exime de responsabilidade penal.

Por fim, ressalto que se faz presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

E isto porque, conforme acima exposto, a dinâmica dos fatos trazida pela prova oral atestou, de forma incontestada, que a prática do tráfico de drogas pelo acusado envolvia o adolescente Gustavo Emanuel Alves Francisco, o qual também foi abordado e apreendido pelos guardas municipais. Estes, aliás, ouviram do menor sua confissão informal a respeito da traficância, ocasião em que ele ainda lhes informou que armazenava mais entorpecentes em sua residência.

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser imposta.

Partindo-se do mínimo legal de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, não vislumbro a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis e que exijam a fixação da pena acima do mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação de pena, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, esta utilizada para convencimento desta magistrada, mas que não têm o condão de diminuir a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, de forma que exaspero a pena em 1/6, chegando a 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, vigente na data dos fatos.

E aqui, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado. Para o reconhecimento da referida benesse necessária a comprovação de uma das hipóteses elencadas no citado dispositivo legal, vale dizer, que o agente (a) não seja primário e de bons antecedentes, (b) dedique-se às atividades criminosas, ou (c) integre organização criminosa.

No caso vertente, embora o acusado seja tecnicamente primário, observo que ele ostenta diversas passagens recentes por ato infracional equiparado a tráfico de drogas na Vara da Infância local (conforme fls. 136/139).

Tal circunstância demonstra que o acusado vinha se dedicando à traficância e fazendo de tal atividade o seu meio de vida, razão pela qual não faz jus ao benefício pleiteado pela Defesa.

No tocante ao regime inicial de pena, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos C. Tribunais Superiores, frente às circunstâncias subjetivas favoráveis e com base no art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para a execução da pena privativa de liberdade, em seu início. Levo em consideração, ainda, consoante supramencionado, a quantidade de pena fixada, superior a 4 anos, além da primariedade do réu.

É nesse sentido que vem decidindo o STJ: "considerando que a pena foi fixada em 2 anos 6 meses de reclusão, pela primariedade do acusado e a análise favorável dos vetores do artigo 59, do CP, mas, por outro lado, tendo em vista a não aplicação da minorante no patamar de 2/3, em razão da quantidade de droga apreendida, deve ser

fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, B e § 3º, do CP- quanto à substituição, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto não recomendam. De fato, embora o quantum de pena fixado seja inferior d 4 anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo, o Tribunal a quo ressaltou que se trata de trafico de quantidade e variedade significativa de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), o que evidencia a gravidade concreta da conduta” (HC 316543, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, julgado em 17.3.2016). Diante do quantum de pena, inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Considerando-se as circunstâncias expostas e a pena a ser aplicada, ressalto que o acusado poderá apelar em liberdade, tal qual já se encontra, ao menos em relação a este feito.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado RIAN WESLEY DE FREITAS, qualificado nos autos, ao cumprimento de uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, vigente na data dos fatos, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com possibilidade de recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 12 de setembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA